

1509983-46.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FERNANDO DE LIMA LUIZ

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... fatos estava próximo a um ponto de tráfico; havia duas garotas e mais um indivíduo; passou uma motocicleta em alta velocidade, visualizou e empreendeu fuga; indagados os que foram abordados, retrataram que conheciam o indivíduo que estava na bicicleta; posteriormente ele retornou e falou que o carro que estava próximo dos abordados era dele; falaram que a motocicleta tinha sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509983-46.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509983-46.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2111416/2020 - 21º D.P. VILA MATILDE, 11277010 - 21º D.P. VILA MATILDE, 1374/20/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2111416 - 21º D.P. VILA MATILDE, 1374/20/221 - 21º D.P. VILA MATILDE, 2111416 - 21º D.P. VILA MATILDE, 1374/20/221 - 21º D.P. VILA MATILDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

LAERCIO BERTELLI JUNIOR e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO DE LIMA LUIZ

Vistos.

1 O relatório

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra João Carlos Alves Mendes e Wesley Rodrigues Feitosa, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP, e contra Laércio Bertelli Junior, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

Narrou a peça acusatória (fls. 1-9) que:

Consta do incluso inquérito policial quena madrugada do dia 6 de maio de 2020, na residência situada na Rua Marieta Xavier, 105, nesta cidade e comarca, JOÃO CARLOS ALVES MENDES (qualificado a fls. 24) e WESLEY RODRIGUES FEITOSA (qualificado a fls. 26), previamente ajustados, agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, a motocicleta KAWASAKI/VERSYS-X 300-A, verde, ano 2018, de placa GBS-1563 - SAO PAULO - SP, avaliada em R\$20.000,00(vinte

mil reais), de propriedade de Pedro Henrique Marcelino Ferreira. Consta, ainda, que no dia 6 de maio de 2020, em horário incerto, nesta capital, LAÉRCIO BERTELLI JUNIOR (qualificado a fls. 22) recebeu de João Carlos Alves Mendes e de Wesley Rodrigues Feitosa, bem como por volta de 06h30, na mesma data, conduziu pela Avenida Professor Xavier de Lima, nesta capital, e pouco depois ocultou na Rua Nelson Madureira, em frente ao número 361, a motocicleta KAWASAKI/VERSYS-X 300-A, verde, ano 2018, de placa GBS-1563 - SAO PAULO - SP, avaliada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), de propriedade de Pedro Henrique Marcelino Ferreira, sabedor de que se tratava de produto de crime.

Apurou-se que no dia 5 de maio de 2020, por volta de 16h00, Pedro Henrique Marcelino estacionou a sua motocicleta KAWASAKI/VERSYS-X 300-A, de placa GBS-1563 - SAO PAULO - SP, na garagem de sua residência situada na Rua Marieta Xavier, 105, cobriu-a com uma capa, trancou o portão da garagem com cadeado e retirou-se.

JOÃO CARLOS ALVES MENDES e WESLEY RODRIGUES FEITOSA, sabedores da existência do veículo na garagem da residência da vítima, decidiram subtraí-lo.

No momento em que lhes pareceu oportuno, os denunciados se dirigiram até a residência da vítima, romperem o cadeado do portão da casa, se dirigiram até a garagem e subtraíram a motocicleta, evadindo-se em sua posse.

Pela manhã do dia 6 de maio de 2020, JOÃO CARLOS e WESLEY ofereceram ao denunciado LAÉRCIO BERTELLI JUNIOR a motocicleta por eles subtraída.

Por volta de 06h30, na Avenida Professor Xavier de Lima, LAÉRCIO, tendo aceitado comprar de JOÃO CARLOS e WESLEY o veículo, o recebeu das mãos dos furtadores, sabedor de que se tratava de bem produto de furto, e passou a conduzi-lo por aquela via pública.

Naquele momento Policiais militares efetuavam patrulhamento pela citada avenida quando avistaram os denunciados JOÃO CARLOS e WESLEY, os quais se dirigiam ao encontro de duas mulheres, e deles suspeitaram, tratando de abordá-los.

As mulheres foram identificadas como Anna Carolyne Pereira e Jeniffer Vitória de Almeida Silva, e no momento em que eram todos interpellados, passou pelo local, na condução da motocicleta produto de furto, o denunciado LAÉRCIO, o qual, por estar conduzindo o veículo sem uso de capacete, chamou a atenção dos policiais.

Nesse instante Anna Carolyne informou aos policiais que o condutor daquele veículo, LAÉRCIO, era o seu namorado, e que tinham pernoitado em um automóvel Gol, que ali estava estacionado, de propriedade daquele. Nenhuma irregularidade constataram os policiais em relação a esse automóvel.

Os policiais então passaram a questionar JOÃO e WESLEY e as mulheres sobre a propriedade e procedência da motocicleta que estava em poder de LAÉRCIO, oportunidade em que aqueles, JOÃO e WESLEY, confessaram que tinham subtraído o veículo naquela manhã, e estavam vendendo ao denunciado LAÉRCIO, indivíduo que havia passado pelo local na condução do veículo.

Logo em seguida LAÉRCIO surgiu ao local, não mais em poder da motocicleta, simulando surpresa na abordagem e identificando-se como proprietário do VW/Gol. LAÉRCIO então foi inquirido sobre o paradeiro da moto e, após prestar informações contraditórias, acabou informando o local onde a havia estacionado.

Os policiais acompanharam LAÉRCIO até o local o ele indicado, mas não localizaram ali o veículo, constatando apenas que se tratava de local de residência do denunciado.

Advertido pelos policiais acerca das consequências de sua conduta, LAÉRCIO então decidiu confessar que havia deixado o veículo "duas ruas para trás, atrás de um caminhão", tratando-se da Rua Doutor Nelson Madureira, em frente ao número 361, onde a moto foi encontrada, sem a respectiva chave, que não foi localizada.

Os policiais pesquisaram o emplacamento de tal veículo e por meio do Copom o seu proprietário foi informado da localização de seu veículo em poder de terceiros. A vítima, que naquele momento desconhecia o furto da motocicleta, constatou que de fato ela havia sido subtraída da garagem de sua residência, mediante arrombamento do portão da moradia, e comunicou o fato aos policiais.

Posteriormente a vítima se dirigiu até o local onde estava estacionado a motocicleta, munido de chave reserva, e se dirigiu até a delegacia para o registro da ocorrência.

Os denunciados receberam voz de prisão e foram conduzidos ao distrito policial, onde se lavrou o incluso auto de prisão em flagrante.

Em decisão de fls. 110-112 foi convertida em preventiva a prisão de Wesley, e liberados Laércio e João Carlos.

Em decisão de fls. 154-155 foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Citado, o acusado Laércio apresentou resposta à acusação à fl. 195.

Em petição de fl. 200, o Ministério Público postulou a aplicação do art. 366 do CPP em relação ao réu João Carlos e a citação do réu Wesley.

O réu João Carlos foi citado por edital (fl. 203).

O denunciado Wesley apresentou defesa prévia às fls. 215-217.

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento em relação aos réus Laércio e Wesley, e, ainda, determinou-se a suspensão do processo e da prescrição em relação ao réu João Carlos (fls. 219).

Após, sobreveio notícia de citação de João Carlos, que apresentou resposta à acusação à fl. 247.

Nova decisão à fl. 260, em que se reconheceu não ser o caso de absolvição sumária e se destacou que a audiência seria realizada na mesma data da anteriormente marcada. Realizado o ato, foi (foram): [a] colhidas provas testemunhais (audiência virtual); e [b] interrogados os réus.

Em audiência, o Ministério Público aditou a denúncia, para fazer constar a qualificadora da escalada (inciso II, § 4º, do art. 155 do CP), o que foi admitido.

Na fase do artigo 402, do CPP, as partes nada requereram.

As partes apresentaram alegações em termo e vieram conclusos.

2 A fundamentação

2.1 O mérito

2.1.1 Os crimes de furto e de receptação

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra João Carlos Alves Mendes e Wesley Rodrigues Feitosa, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP, e contra Laércio Bertelli Junior, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

A materialidade e a autoria são comprovadas pelos seguintes elementos: [a] auto de exibição e apreensão (fls. 27-28); [b] auto de entrega (fls. 29-30); [c] laudo pericial de fls. 292-296; e [d] depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, os autos acima indicados demonstram a apreensão do veículo motocicleta Kawasaki Versys-X 300 A, de placas GBS1563, em posse de um dos réus e posteriormente entregue ao legítimo proprietário.

Ademais, ouvido em audiência, a vítima Pedro Henrique Marcelino Ferreira afirmou que foi numa manhã, sendo acordado com um telefonema da delegacia, perguntando se a motocicleta havia sido furtada; mora nos fundos e foi verificar; foi na garagem, que é na parte de cima, e a garagem estava com cadeado arrombado e a moto não estava no local; retornou e confirmou a subtração; o pessoal da delegacia orientou para que fosse até lá para fazer os trâmites da recuperação do bem; o cadeado foi arrombado do portão, até com o uso de ferramentas da própria vítima e tinha um pedaço de pano com sangue, porque acredita que se machucaram ao entrar; depois até trocou o portão; tinha um vão no portão, provavelmente pularam ali e pegaram um martelo, com o qual conseguiram quebrar o cadeado; acredita que o portão tinha 2 (dois) metros de altura; e foi no dia anterior que deixou a motocicleta na garagem, na parte da tarde.

O Policial Militar Roberto Wagner Barbosa dos Santos Junior informou que recorda da ocorrência; estavam em patrulhamento e verificaram que havia duas garotas e dois homens que estavam mexendo em um carro e saíram correndo quando viram os policiais; abordaram todos, passou o Laércio com uma moto, sem capacete e em alta velocidade; conseguiram visualizar a placa parcialmente e ele passou direto e foi embora; continuaram a abordagem para verificar o carro; durante esse período, o réu Laércio retornou; perguntaram da moto, ele demorou para falar e depois confessou; disse que os outros dois indivíduos haviam passado e levou até onde tinha a moto; o réu falou

que havia sido furtado por outras duas pessoas, mas não recorda de onde; se recorda que o dono da moto nem sabia que havia ocorrido o furto; quando conseguiram contato com o dono, ele estava dormindo, e foi ver e o portão estava estourado e a motocicleta não estava no local; não se recorda se ele comprou ou recebeu; apenas lembra que falou que não era ele que tinha pego a moto; os outros indivíduos falaram que tinham furtado a motocicleta; o que ele iria fazer com a motocicleta não sabe; e não se recorda das mulheres.

O Policial Militar Renato Silva dos Reis disse que na data dos fatos estava próximo a um ponto de tráfico; havia duas garotas e mais um indivíduo; passou uma motocicleta em alta velocidade, visualizou e empreendeu fuga; indagados os que foram abordados, retrataram que conheciam o indivíduo que estava na bicicleta; posteriormente ele retornou e falou que o carro que estava próximo dos abordados era dele; falaram que a motocicleta tinha sido produto de furto; a motocicleta estava dentro da garagem, arrombaram o portão e entraram; e quando retornou, o réu falou que participou do furto com os dois primeiro.

Interrogado, o réu João Carlos Alves Mendes gizou que a acusação é verdadeira; à época fumava muito crack; teve esses defeitos, mas hoje não tem mais; estava em uma favela; quebrou o calcanhar; não estava aguentando andar, viu a motocicleta; pegou a turquesa que estava na mochila e estourou o cadeado; foi para casa, encontrou o Wesley, perguntou se queria dar umas voltas; saíram então com essa moto; apareceu na mão do Laércio e a polícia; conseguiu abrir o portão depois de estourar o cadeado; estava sozinho quando praticou o ato; acredita que o Wesley foi denunciado porque estava junto andando com a motocicleta; não estava junto com o Laércio; quando a polícia apreendeu, o Laércio estava andando e o interrogado estava longe junto com o Wesley; não teve nenhuma transação com o Laércio; a motocicleta não era para ser vendida, era somente para andar com ela; não chegou a pular o portão, foi simplesmente com a turquesa que estourou o cadeado; a garagem era normal; estava com o pé machucado para cometer o ato; encontrou o Wesley na rua, no Vila Matilde; já tinha visto o Wesley algumas vezes no bairro; conhecia de rua; primeira vez que viu o Laércio foi a vez da motocicleta; não tentaram vender, ele só pediu para dar uma volta com a motocicleta e o interrogado deixou; e ele foi dar uma volta no quarteirão e os policiais chegaram; e o cadeado estava do lado de fora do portão.

Interrogado, o réu Laércio Bertelli Junior aduziu que estava com o carro parado na rua; esses dois rapazes passaram com a motocicleta; falaram que queriam vender a motocicleta; o interrogado falou que um amigo compraria; não tinha ciência de furto; puxou a placa do sistema e constatou que estava normal; quando voltou, os réus estavam enquadrados do lado do carro; levou o policial onde estava a motocicleta; ficaram até o meio dia lá; estava tudo certo na concepção do interrogado, senão não teria voltado; não conhece os demais réus; os demais ofereceram, dizendo que estavam vendendo a motocicleta, disse que tinha um amigo interessado e pediu para dar uma volta; não ia comprar a motocicleta, mas queria ver; deixou no mesmo local em que eles indicaram; encostou no mesmo lugar que eles deixaram a motocicleta; não perguntou sobre eventual documento da motocicleta para dar uma volta; tinha bastante gente andando com a motocicleta; não recorda qual dos dois falou em vender a motocicleta, mas acredita que os dois; acha que talvez o moreninho (o João); foi o João que apareceu com a motocicleta; ele parecia estar chapado e estava com o pé machucado, mas nunca tinha visto ele na rua; não chegaram a tratar de preço; e viu que a polícia estava lá e que eles estavam sendo abordados, e entendeu que estava tudo certo.

Interrogado, o réu Wesley Rodrigues Feitosa salientou que o João, que conhece por morar perto da casa de vista, apareceu com a motocicleta com perto de carro; ele falou a verdade, que era furtada e foram dar uma volta; foram parar em uma quebrada, perto de onde moram, mas um pouco mais distante; viram o Laércio, que se interessou pela moto e disse que queria comprar; polícia em seguida abordou os acusados; o furto não cometeu; aceitou sair com ele numa boa; tinha ciência de que era furtada; aceitou sair na motocicleta com ele porque conhecia de vista; João falou que tinha furtado; pediu para levar na quebrada para irem usar drogas juntos, onde mora o Laércio; o Laércio foi dar uma volta primeiro, não tinha dito que iria comprar nem nada, e foi quando os policiais chegaram.

Do que se viu, portanto, na data dos fatos, os acusados João e Wesley subtraíram bem alheio móvel, consistente em uma motocicleta, acima descrita, em concurso de agentes e com o rompimento do obstáculo (cadeado existente no portão), em período noturno (durante a madrugada).

Com efeito, os réus romperam um cadeado existente no portão da garagem da vítima e conseguiram subtrair a motocicleta, somente vindo a serem descobertos em razão da ação de policiais e da confissão perpetrada após investigações, inclusive com abordagem das pessoas ora ouvidas como testemunhas. Além disso, realizaram escalada para adentrar no local.

Nesse sentido, constou no laudo pericial de fls. 292-296 que: [a] segundo informes, o indivíduo escalou o portão e entrou na garagem pelo vão livre existente entre a porção superior do portão e a laje que recobre a garagem. Já dentro da garagem empreendeu violência contra o cadeado do portão; e [b] “pode-se constatar vestígio de avaria no cadeado do portão, caracterizado por amolgamento em uma das suas hastes, produzidos por instrumento desconhecido a guisa de alavanca”.

Incidiram, assim, no disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP, devendo responder pelas penas a ele cominadas.

Ademais, o réu Laércio, sabedor da origem furtiva do bem, aceitou comprá-lo, de modo que este incidiu no disposto no art. 180 do CP.

Acerca das teses das defesas, cabe destacar que o acervo probatório é suficiente para a condenação. Os réus apresentam versões distintas e confusas entre si.

Ademais, pela própria dinâmica das investigações, que culminou na abordagem dos acusados, possível verificar a discrepância em relação ao que efetivamente ocorreu. Não é crível que o réu João tenha realizado toda a ação sozinho para, somente então, encontrar Wesley e este, sem o conhecer, aceitar andar de motocicleta que, segundo o próprio narra, era produto de furto. Além disso, João disse não ter realizado escalada, porém, pelo relato da vítima, verifica-se que esta ocorreu para conseguirem o intento criminal. Veja-se, inclusive, cadeados não ficam para o lado de fora em situações como a presente (porque as pessoas o fecham por dentro, após entrarem).

O réu Laércio aduz que não sabia da origem ilícita e que não tinha a intenção de comprar o bem, porém o réu Wesley aduziu ver a negociação ocorrendo e, ademais, não haveria motivos para andar na motocicleta se não tivesse a intenção de compra. Além disso, não é crível que o réu Laércio desconhecia a origem espúria da motocicleta, na medida em que fazia a aquisição sem exigir qualquer documento ou elemento mínimo comprobatório da titularidade, sendo que é de conhecimento geral que automóveis possuem documentação.

Além disso, não há qualquer dúvida sobre a imputabilidade dos demandados em relação a tais fatos, o que sequer chegou a ser ventilado na hipótese.

2.2 A dosimetria da pena

2.2.1 O réu João Carlos Alves Mendes

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu João Carlos Alves Mendes, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] não há maus antecedentes a serem considerados; [c] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [d] os motivos (as razões de sua prática) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [e] o comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva.

As circunstâncias do crime, entretanto, devem ser valoradas negativamente. Isso porque foram verificadas três qualificadoras (com destruição de obstáculo, com escalada e por duas pessoas), de modo que uma permanece na terceira fase, enquanto as outras migram para a primeira fase da dosimetria.

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses

de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a existência da agravante da reincidência (processo n. 1523728/2021, fl. 251) e a inexistência de atenuantes. Saliento que: [a] “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e [c] “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, majoro a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena-provisória em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco que, a despeito da existência da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de repetitivo (vinculante, portanto), não é possível a aplicação do § 1º ou furto qualificado, isso em razão da posição topológica da previsão.

Diante disso, mantenho como pena-definitiva o mesmo patamar anteriormente apontado. Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o semiaberto, em razão do montante da pena e da existência de reincidência (art. 33, § 2º, 'b', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito” (Súmula n. 440 do STJ); [b] “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula n. 719 do STF); e [c] “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão da reincidência específica e da circunstância negativa, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito (art. 44 do CP) ou de realizar a sua suspensão condicional (art. 77 do CP).

2.2.2 O réu Laércio Bertelli Junior

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu Laércio Bertelli Junior, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] não há maus antecedentes a serem considerados; [c] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [d] os motivos (as razões de sua prática), as circunstâncias (modo em que ocorreu) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [e] o comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva.

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a inexistência de agravantes ou de atenuantes.

Saliento que: [a] “a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já

destacado acima, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ); e [c] “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal” (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, mantenho como pena provisória o mesmo patamar.

Ante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo como pena definitiva o mesmo patamar acima previsto para a pena-provisória.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o aberto, em razão do montante da pena e da inexistência de reincidência (art. 33, § 2º, 'c', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito” (Súmula n. 440 do STJ); [b] “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula n. 719 do STF); e [c] “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula n. 269 do STJ).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] o réu não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram todas neutras).

Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese (condenação em 1 anos) deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP).

2.2.3 O réu Wesley Rodrigues Feitosa

No que tange à dosimetria da pena, em relação ao réu Wesley Rodrigues Feitosa, destaco, na primeira fase (pena-base), que, de acordo com o art. 59 do CP: [a] a culpabilidade (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie; [b] inexistem informações suficientes acerca da conduta social (meio como se comporta no seio da sociedade) ou da personalidade (características pessoais advindas de sua psique); [c] os motivos (as razões de sua prática) e as consequências (situações advindas da prática) também não se apresentam destoantes do que normalmente se espera nesses casos; e [d] o comportamento da vítima em nada contribuiu com a prática delitiva. Devem ser valoradas negativamente, entretanto: [a] as circunstâncias do crime, entretanto, devem ser valoradas negativamente. Isso porque foram verificadas três qualificadoras (com destruição de obstáculo, com escalada e por duas pessoas), de modo que uma permanece na terceira fase, enquanto as outras migram para a primeira fase da dosimetria; e [b] os maus antecedentes (autos de n. 0013051-21.2006.8.26.0050, fls. 180-181).

Saliento, por oportuno, que: [a] “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula n. 444 do STJ); e [b] “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula n. 241 do STJ).

Assim, majoro a pena em 1/5 e fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase (pena-provisória), destaco a existência da agravante da

reincidência (processos ns. 0008234-30.2012.8.26.0008, fl. 180; 0007812-12.2015.8.26.0635, fl. 180; 0067326-75.2010.8.26.0050, fls. 181-182; e 0086783-15.2018.8.26.0050, fls. 182-183) e a inexistência de atenuantes.

Saliento que: [a] "a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ), o que, por consequência, também inviabiliza sua majoração além do máximo; [b] nos termos do já destacado acima, "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241 do STJ); e [c] "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (Súmula n. 545 do STJ).

Diante disso, majoro a pena em 1/4 (um quarto) e fixo a pena-provisória em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase (pena-definitiva), destaco que, a despeito da existência da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de repetitivo (vinculante, portanto), não é possível a aplicação do § 1º ou furto qualificado, isso em razão da posição topológica da previsão.

Diante disso, mantenho como pena-definitiva o mesmo patamar anteriormente apontado. Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), entendo que é matéria afeta à execução penal (art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal). Ademais, não houve prisão preventiva na hipótese.

Estabeleço: [a] como regime inicial, o semiaberto, em razão do montante da pena e da existência de reincidência (art. 33, § 2º, 'b', do CP); e [b] o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, § 1º, do CP), notadamente por não haver outros elementos que possam indicar em sentido contrário.

No ponto, cabe destacar que: [a] "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (Súmula n. 440 do STJ); [b] "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula n. 719 do STF); e [c] "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou superior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269 do STJ).

Em razão da reincidência específica e da circunstância negativa, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito (art. 44 do CP) ou de realizar a sua suspensão condicional (art. 77 do CP).

2.3 A indenização mínima

Deixo de fixar indenização mínima para a hipótese vertente, porquanto não houve pedido expresso nesse sentido na denúncia, o que impede sua concessão, conforme entendimento da Corte de Cidadania (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Ademais, mesmo que realizado o pedido em alegações finais, tal situação não é suficiente para fins de concessão, notadamente por inviabilizar o contraditório e a ampla defesa acerca do tema.

2.4 A prisão preventiva

Os réus poderão apelar em liberdade, porquanto: [a] não apresentados indicativos da imprescindibilidade da segregação processual neste momento; e [b] responderam ao processo em liberdade.

3 Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no art. 387 do Código de Processo Penal condeno: [a] o réu João Carlos Alves Mendes pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; [b] o réu Wesley Rodrigues Feitosa pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do CP, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto; e [c] o réu Laércio Bertelli Junior pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 1 (um) ano de

reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP), nos termos da fundamentação supra.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais. Contudo, a respectiva exigibilidade está suspensa, durante o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, em face da presunção de hipossuficiência financeira, consoante arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC.

Os réus poderão apelar em liberdade.

Declaro o perdimento de eventual arma de fogo e de munição apreendida em favor da União (art. 91, II, alínea 'a', do CP), para os fins dos arts. 25 e 32, parágrafo único, do Estatuto do Desarmamento, se o caso.

Determino a perda de eventual fiança, cujo valor será vertido para pagamento das despesas processuais e de eventual indenização para vítima, nos termos do art. 336 do CPP, se o caso.

Determino a destruição de eventuais drogas ainda existentes, se o caso.

Fixo a remuneração do advogado dativo no máximo previsto na tabela da DPE/OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpridas todas as determinações, arquivem-se.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA